主題：試題演練

壹、甲為知名歌手，某日出席粉絲見面會時，提供廣大粉絲簽名服務，不肖人士乙持甲肖像之廣告授權書給甲簽名，當下粉絲見面會人數眾多，甲分身乏術，無法確認紙張內容，因此誤以為授權書僅是無意義之紙張，遂在上面簽名，乙之詭計得逞，於是在自家所販賣的衣服上印上甲之肖像，存貨於自家倉庫，作為周邊商品販賣，並且備份甲之照片，預計之後在電腦上設計印有甲肖像之馬克杯進行量產販售，甲得知後大為光火，委任律師對乙提告。試問：

一、甲、乙之授權契約是否成立？

二、甲得對乙為如何之主張？

貳、甲飼養可愛秋田犬 A，A 平日好玩好動、精力旺盛，甲明明數次遭反映噪音會傳到鄰居住所，但半夜十二點也與 A 玩傳接球遊戲，然而鄰居法律系國考生乙卻因甲與 A 遊戲之噪音連續數月而不勝其擾，乙因此失眠導致學業退步而精神崩潰，甚至需要求助失眠門診支出掛號費用，遂請環保局到場檢測噪音，發現甲與 A 遊戲之噪音超標，環保局遂對甲進行勸導，孰料甲竟變本加厲，一整夜與 A 練習狼嚎，乙認為士可忍，孰不可忍，於是在甲、A 平日例行散步的道路上丟棄 A 愛吃的鴨氣管並塗上大量巧克力，A 在散步過程中無法抵禦美食的誘惑，吃下氣管後遂死亡[1]。試問：

一、在 A 死亡前，乙得對甲為如何之主張？

二、就 A 死亡一事，甲得對乙為如何之主張？

[1] 本件事實純屬虛構，現實上並無任何秋田犬受到傷害。

壹、

一、甲、乙之授權契約不成立

(一) 按民法第 153 條第 1 項，當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立。而本件甲對於該授權契約簽名承諾之意思表示是否成立？應視意思表示之必要要素是否具備。

(二) 所謂表示意思，係指表意人內心意識其表示行為具有某種法律意義、得發生某種法律效果的意思。查本件甲在簽名時僅是認為在粉絲的紙張上簽名留下紀念，並無發生任何法律效果之意思，應認為並不具備表示意思。

(三) 若欠缺表示意思，意思表示是否因此不成立？取決於表示意思是否為意思表示之必要要素，討論如下：

1. 否定說認為，表示意思並非必要要件，表意人內心是否有表示意思，相對人難以查證，因此基於交易安全之保護，應該認為表示意思並非必要要件。
2. 肯定說認為，表示意思仍為意思表示之必要要件，若有欠缺則不生效力，否則無法解釋為何好意施惠行為不生拘束效力。
3. 本文採取肯定說，理由在於交易安全之保護，可以透過客觀解釋意思表示，自理性第三人的客觀判斷，若表意人之行為足以令相對人信賴其認識將發生某種法律效果，此時即應承認表意人具有表示意思，如此即可保障交易安全。

(四) 查本件甲簽名時所在時間地點為粉絲見面會，自理性第三人角度觀之，粉絲遞上的紙張應該都僅是作為簽名留念之用，並不應該出現肖像授權書，是以，根本無法使相對人乙信賴會發生授權之法律效果，欠缺表示意思，該簽名之意思表示自不成立，授權之法律行為自無法因為甲、乙意思表示合致而成立。

二、本件分述如下：

(一) 甲得依民法第 184 條第 1 項前段向乙請求財產上損害與非財產上損害之損害賠償

1. 本件乙故意使用甲之照片印在衣服上，侵害甲之肖像權，然而本件乙之行為是否具有不法性，應以利益衡量判斷，討論如下：
2. 乙之行為具有不法性

本件乙並未獲得甲之授權已如前述，又甲雖然是公眾人物，然而該肖像之使用應該也只限於新聞之報導，並非可以做為商業使用，否則可能會侵害甲作為明星本身之可獲得之商業利益，更何況乙若真有意願販售甲之周邊商品，也應該循正當管道取得甲之同意，是以，本件侵害行為應該具有不法

性。

3. 綜上，侵權行為責任成立，本件侵害甲之肖像權，而肖像權屬於人格權，按民法第 18 條第 2 項，人格權受侵害時，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。以下討論損害賠償之範圍：
   (1) 財產上損害
      a、 按民法第 215 條，不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害。
      b、 本件甲之肖像權被乙使用後已經無法回復到未使用之狀態，應該賠償甲原先若依市場上授權時可取得之授權金。
   (2) 非財產上損害
      a、 按民法第 195 條第 1 項前段，不法侵害他人格權而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。
      b、 本件乙侵害甲之肖像權，而肖像權屬於民法第 195 條第 1 項前段所規範之人格權，甲亦因此大為光火而有精神上痛苦，故得請求非財產上損害之損害賠償

(二) 甲得依民法第 179 條向乙請求返還相當於使用甲肖像費用之不當得利
1. 按民法第 179 條，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。
2. 本件乙使用甲之肖像印在衣服上而受有利益，甲亦因此受有肖像遭他人使用之損害，乙也未獲得甲之授權如前述，故乙使用甲之肖像並無法律上之原因，構成不當得利。
3. 次按民法第 181 條，不當得利之返還原則上應該原利益返還；例外於原利益返還不能時，依客觀說返還相當於客觀市價之價額。
4. 查本件甲之肖像被乙印在衣服上使用即無法依原樣返還給甲，屬於民法第 181 條但書所稱利益返還不能之狀況，應將甲之肖像使用折算通常使用應支付之相當對價作為不當得利之返還。

(三) 甲得依民法第 18 條第 1 項前段請求乙銷毀庫存之衣服
1. 按民法第 18 條第 1 項前段，人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害。
2. 查本件乙印製甲之衣服乃侵害甲之肖像權，而該侵害具有不法性已如前述，甲得請求乙除去侵害。

3. 而除去侵害之方法，因為乙印製之衣服仍在乙之倉庫，是以，甲得請求乙銷毀該批衣服而除去肖像權之侵害。

(四) 甲得依民法第 18 條第 1 項後段請求乙刪除甲之照片

1. 按民法第 18 條第 1 項後段，人格權有受侵害之虞時，得請求防止之。
2. 而本件甲之照片乙仍存有備份，乙甚至之後打算做為生產馬克杯之用，有再度侵害甲肖像權之虞，是以，甲應該可以預防該侵害之發生。
3. 而預防侵害之方法，應係請求乙刪除該備份甲之照片，避免乙後續繼續使用甲之照片作為商品販售之用。

貳、

一、本件分述如下

(一) 乙得依民法第 18 條第 1 項前段請求甲停止噪音之製造

1. 按民法第 18 條第 1 項前段，人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害。
2. 實務見解認為，居住安寧之人格利益應為我國所保障之人格法益，若發出超過一般人所能忍受之噪音，屬於居住安寧人格法益之侵害[2]。
3. 查本件甲日夜與 A 玩傳接球遊戲，時間在半夜十二點，應該是社會一般大眾休息之時間，更何況甲、A 係日以繼夜的遊戲，侵害程度更大，且噪音之程度甚至超過環保局之規定而遭勸誡，應該認為超過一般人所能忍受之範圍，構成居住人格法益之侵害
4. 而該侵害是否具有不法性，應進行利益衡量。查本件甲若欲與 A 玩耍，實可在日間進行，或是到戶外玩耍，尚不至於鄰居乙無法忍受，是以，應具有不法性。
5. 綜上，乙應可請求甲停止製造噪音。

(二) 乙得依民法第 184 條第 1 項前段向甲請求掛號費用之財產上損害以及非財產上損害之損害賠償

1. 本件甲構成居住安寧之侵害已如前述，而甲多次遭鄰居提醒，可以甲明知噪音之情事，故有故意，且該侵害具有不法性如前述，故甲構成侵權行為。
2. 本件侵害乙之居住安寧之人格法益，而居住安寧屬於一般人格權，按民法第 18 條第 2 項，人格權受侵害時，以法律有特別規定者為限，得請求損害賠償或慰撫金。以下討論損害賠

[2] 「於他人居住區域發出超越一般人社會生活所能容忍之噪音，應屬不法侵害他人居住安寧之人格利益，如其情節重大，被害人非不得依民法第一百九十五條第一項規定請求賠償相當之金額。」最高法院 92 年度台上字第 164 號民事判決參照。

償之範圍：

(1) 財產上損害之損害賠償

a、 按民法第 215 條，不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害。

b、 本件乙過去受侵害之居住安寧人格法益已經無法回復，故乙得請求甲賠償該居住安寧受侵害而支出之掛號費用之財產上損害。

(2) 非財產上損害之損害賠償

a、 按民法第 195 條第 1 項前段，不法侵害他人格權而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。

b、 本件乙之居住安寧受到侵害而夜夜難眠，甚至需要去看醫生可見其精神上受有巨大痛苦，應可請求非財產上損害之損害賠償。

二、本件分述如下：

(一) 甲得依民法第 184 條第 1 項前段向乙請求 A 犬客觀市價之財產上損害之損害賠償

1. 本件甲係 A 犬之所有人，而乙明知犬隻攝入巧克力可能會死亡，卻仍在甲、A 散步路上放置含有巧克力之食物，導致 A 吃下巧克力而死亡，乙係故意侵害甲之「所有權」，成立民法第 184 條第 1 項前段之侵權責任

2. 按民法第 215 條，不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害。查本件 A 犬已經死亡無法復生，故無法回復原狀，甲得請求乙賠償 A 犬之客觀市價。

3. 次按民法第 18 條第 2 項、民法第 195 條第 1 項前段，僅有「人格權」受侵害時方可請求非財產上損害之損害賠償。本件甲若係 A 犬之「所有權」受侵害，甲並無法請求非財產上損害之損害賠償。

(二) 甲不得依民法第 184 條第 1 項前段向乙請求 A 犬死亡之非財產上損害之損害賠償

1. 本件乙是否因為害死 A 犬而侵害甲之其他人格法益？討論如下：

(1) 實務上有見解認為，應認「寵物」非物，而是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」，對加害人侵害寵物之行為故寵物係受傷或死亡時，飼主得類推適用民法第 195 條第 1 項請求非財產上之損害賠償。

(2) 惟本文認為，實務類推適用民法第 195 條第 1 項有所不妥，理由在於飼主與寵物之關係更接近於第 3 項之情

況，並不符合類推適用之要件。

(3) 是以，本件甲之 A 犬雖然被乙侵害致死，但是甲並無其他人格法益受侵害。

2. 而本件乙是否因為害死 A 犬而侵害甲民法第 195 條第 3 項之人格法益？討論如下：

(1) 或有認為，因為民法第 195 條第 3 項並不包含寵物，基於保護動物之意旨，應類推適用民法第 195 條第 3 項而請求非財產上損害。

(2) 亦有認為類推適用民法第 195 條第 3 項則因立法者有意限縮人格法益的保障範圍，故非法律漏洞，而無類推適用之餘地。然而，若基於動物保護之意旨，應為制定法外之法之續造，而可依民法第 1 條作為法律基礎，請求非財產上損害之損害賠償。

(3) 然而本文認為上開見解均不足採，理由在於兄弟姊妹受侵害致死時尚且不可請求非財產上損害之損害賠償，何以寵物致死即可，是以，為了避免價值判斷輕重失衡，應否定寵物受侵害時得請求非財產上損害之損害賠償。

3. 綜上，甲不得依民法第 184 條第 1 項前段向乙請求 A 犬死亡之非財產上損害之損害賠償。